「**Standing Firm, on Forbidden Grounds**」

리처드 A. 엡스타인

이 호에 실린 글들은 샌디에이고 대학교 법학전문대학원과 리버티 펀드가 내 책 *Forbidden Grounds: The Case Against Employment Discrimination Laws*를 둘러싸고 개최한 심포지엄의 산물이다. 이 글들이 내가 그 책에서 제시한 논지에 상당한 반대 입장을 담고 있다는 점은 분명하다. 내가 그 책에서 내세운 주장은 다음과 같다. 곧 인종, 종교, 성별, 연령, 장애 등 어떤 이유에서든 고용주가 차별하는 것을 금지하는 반차별법은, 적어도 경쟁적 시장에서 활동하는 민간 고용주에게 적용되는 한, 법전에서 삭제되어야 한다는 것이다.

나는 *Forbidden Grounds*에서, 가장 악질적이고 열성적인 백인우월주의자가 실행하는 차별이든, 다양성이나 적극적 우대조치를 열렬히 지지하는 사람이 실행하는 편애든, 사적인 차별이나 편애를 모두 허용하는 법질서가 사회 전체적으로 가장 나은 결과를 낳는다고 주장했다. 내 책의 핵심 주제 중 하나는, 내용이 아무리 고상하고 목적이 아무리 숭고하더라도, 어떠한 반차별법이든 그것을 정부가 집행할 때 오히려 훨씬 더 큰 폐해가 발생할 가능성이 높다는 점이다.

*Forbidden Grounds*는 현행 법체제를 대체할 경쟁적 질서가 모든 경우에 완벽한 결과를 낳을 것이라는 가정 위에서 쓰인 책이 아니다. 또한 시장이 차별의 모든 부정적 결과를 제거할 것이라고, 혹은 제거해야 한다고 주장하는 책도 아니다. 다른 어떤 사회적 관행이든 마찬가지다. 인간이 만든 어떤 제도도 그런 결과를 달성할 수 없고, 또 그래야 한다고 요구받아서도 안 된다. 나는 경쟁시장이 모든 형태의 차별을 제거할 것이라고도, 제거해야 한다고도 주장하지 않는다. 오히려 그 반대다.

나는 복잡한 고용관계 속에서는 어떤 형태의 사적 차별, 즉 인종·성별·연령·장애를 이유로 한 일정한 차별이 여기저기 남아 있을 것이라고 본다. 다만 악의적이고 해로운 차별은 남지 않을 것이다. 경쟁시장의 한 경향은 비효율적인 행동양식을 몰아내는 데 있으며, 차별도 예외가 아니다. 따라서 모든 경우에 적절한 전략은 시장 진입을 가능한 한 신속하게 개방하고, 고용관계에 가로놓인 장애물들—실업 관련 과세, 최저임금, 반차별법, 대부분의 산업안전 규제—을 최대한 제거하여, 고용주와 노동자가 상호 합의 가능한 조건 아래 각자의 평화를 찾도록 하는 것이다.

이러한 기본 논지를 전제로, 나는 심포지엄에서 제기된 반복적인 비판들, 그리고 이 호를 위해 심포지엄 이후 따로 쓰인 비판들에 답하고자 한다. 어떤 경우에는 심포지엄에서 발표된 개별 논문들을 직접 언급할 것이고, 어떤 경우에는 출처를 특정하지 않은 채 토론 과정에서 제기된 쟁점들에 원칙적으로 응답할 것이다. 그래서 이 글의 전반부는 주로 이론적 문제를, 후반부는 실증적·역사적 문제를 다룬다.

제1부는 특히 *Forbidden Grounds*와 나의 작업 전반에서 공리주의적 기초와 자유지상주의적 기초가 어떻게 관계하는지를 탐구한다. 제2부는 한편의 강제와 사기, 다른 한편의 차별 사이에 있다고 여겨지는 유사성을 검토한다. 제3부는 차별이 야기하는 심리적 피해에 대해 법이 어떤 대응을 해야 하는지 살핀다. 제4부는 차별적 관행을 사회가 용인할 때 발생하는 상징적 피해와 사회적 의미를 다룬다. 제5부는 내 견해를 공공편의시설, 주택시장, 자동차 소매시장으로 확장할 수 있는지 검토한다. 제6부는 1964년 민권법 제정 이전 남부와 북부에서의 역사적 차별 관행을 살핀다. 마지막 제7부는 양도 가능한 쿼터 문제를 염두에 두고 "이제 어디로 갈 것인가"라는 불편한 질문을 던진다. 내 견해로는, *Forbidden Grounds*에 가해진 모든 반론을 검토해볼수록 민권입법을 전면 폐지해야 한다는 지적 논거는 오히려 더 강해진다.

I. 공리주의인가, 자유지상주의인가?

가장 끈질기게 제기된 이론적 비판은 반차별법을 다룰 때 어떤 철학적 지향을 택해야 하느냐는 문제였다. 특히 브릴메이어 교수의 글은 *Forbidden Grounds* 안에 나타난 철학적 지향의 복수성과 무원칙성을 비판한다. 이 점에서 그녀가 혼란을 느낀 것은, 지난 20여 년 동안 내 법철학적 입장이 변화해온 과정을 생각하면 어느 정도 이해할 수 있다. 내가 자연권적 자유지상주의자에서 제한정부를 지지하는 공리주의자로 천천히 이동해온 과정을 일일이 설명하는 대신, 여기서는 현재 내 입장만을 밝히겠다.

이 입장의 핵심에는 다음과 같은 생각이 있다. 법적 권리는 사회 전체의 효용 수준을 극대화하기 위해 인간이 의식적으로 만들어낸 제도이며, 따라서 공적 강제력의 사용은 광범위한 사회복지 증진에 기여할 가능성이 높은 과업들로 한정되어야 한다는 것이다. 이러한 법적 틀은 국가 개입의 두 가지 주요 근거를 낳는다.

첫째, 국가의 기본 기능은 사적 강제를 통제하는 것이다. 다시 말해, 한 사람이 다른 사람의 신체나 재산에 가하는 공격을 공적 강제로 제어하는 것이다. 그 연장선에서 정부는 사기와 허위표시의 여러 형태도 제한해야 한다. 둘째, 국가는 자발적 거래가 잠재적 교환이익을 모두 실현하지 못하게 하는 거래비용상의 장애를 극복하기 위해 공적 강제를 사용할 수 있다. 그래서 어떤 입법이 각 당사자에게 그들이 포기한 권리와 적어도 같은 수준의 이익을 제공한다면, 국가는 정당한 보상을 전제로 사유재산을 공공목적으로 취득할 수 있다. 그 보상은 반드시 현금일 필요는 없다. 이러한 정부권한은 한편으로는 광범위하지만, 다른 한편으로는 엄격히 제한된다. 즉 경찰력을 유지하기 위한 조세 부과, 공공재 공급, 사적 독점의 통제는 허용되지만, 조세·규제·책임법 수정 등을 통해 한 사람의 재산을 전부 또는 일부 빼앗아 다른 사람에게 이전하는 것은 허용되지 않는다.

이 정부권한의 정확한 윤곽은 지금의 논의와 직접 관련된다. 그것은 왜 국가가 어떤 개인이나 집단이 다른 개인이나 집단에게 가하는 사적 폭력을 막기 위해 강제력을 사용해

도 되고, 오히려 사용해야 하는지를 설명해준다. 또 국가가 독점을 금지하는 것이 왜 정당할 수 있는지도 설명해준다. 다만 어떤 경우든 그러한 사적 불법행위를 통제하는 비용이, 그로써 막을 수 있는 해악보다 더 큰지를 따져야 한다. 그런데 대부분의 고용관계를 특징짓는 경쟁시장에서는, 이러한 국가개입의 두 근거가 모두 성립하지 않는다. 그런 상황에서 *Forbidden Grounds*의 핵심 명제는, 잘 정립된 재산권 체계 안에서 이루어지는 상호 교환이 어떠한 정부개입 체계보다 더 나은 결과를 낳는다는 것이다.

이 기본 틀은 철저한 의미의 자유지상주의는 아니다. 왜냐하면 개인의 자율성과 상호 교환 자체를 법질서의 최종적 기초가치로 삼지 않기 때문이다. 그러나 민간 주체에게 반차별원칙을 적용할 것인가라는 문제는 강제, 사기, 독점의 문제가 이미 해결되었거나 적어도 옆으로 제쳐진 뒤에야 비로소 등장한다. 그렇다면 이제는 강한 재산권과 계약의 자유를 강조하는, 파생된 의미의 자유주의 원리 안에서 개별 사안을 평가하는 것이 적절하다. 여기서 계약의 자유는 행동의 자유, 양심의 자유, 표현의 자유와 마찬가지의 존중을 받아야 한다. 고용시험 제한, 보험, 정년제, 장애에 대한 합리적 편의 제공 등 반차별법의 여러 교리들에 대한 내 비판이 중요한 이유는 바로 이것들이 책의 중심 전제—강제·사기·독점이 문제 되지 않을 때 국가개입은 순사회적 손실을 낳는다—를 뚜렷하게 드러내기 때문이다.

II. 강제, 사기, 그리고 차별

심포지엄에서 끊임없이 제기된 두 번째 질문은, 강제와 사기는 금지행위 목록에 넣으면서도 사적 차별은 그 목록에서 제외하는 개념적 틀을 만들 수 있느냐는 것이었다. 나는 *Forbidden Grounds*에서 제시한 논증이 그러한 공격을 견뎌냈다고 생각한다.

강제 금지는 단순한 홉스적 통찰에서 출발한다. 우리는 모두 다른 사람의 생명이나 신체를 해칠 수 있는 능력보다, 자신의 생존과 신체적 온전함을 더 소중히 여긴다. 따라서 사회의 모든 구성원이 동시에 구속되는 명시적 계약은 현실적으로 불가능하더라도, 모두가 서로에 대한 강제 사용을 포기하는 합리적 사회계약을 구상하는 것은 가능하다.

이 논문집에 실린 매커덤스 교수의 글은, 내가 제한정부론을 설명하기 위해 홉스적 개념에 의존하는 것을 거칠게 비판한다. 그는 보통의 동의로는 사회계약의 작동을 설명할 수 없고, 게다가 홉스 자신은 타이틀 VII보다 훨씬 더 가혹한 명령도 부과할 수 있는 절대주권자를 지지했다고 말한다. 그러나 이 비판은 두 점 모두에서 빗나간다. *Forbidden Grounds*는 정치적 의무의 문제를 다룬 것이 아니라 이미 국가가 존재한다는 점을 전제하고 있었다. 반면 *Takings*는 바로 그 문제를 다루었고, 나는 সেখানে 홉스가 정치지배의 문제를 가장 날카로운 형태로 제기했지만, 그 자신이 제시한 해법보다 로크적 해법이 훨씬 낫다고 길게 논했다.

매커덤스의 엉뚱한 비판은 접어두고, 이 사회계약에 실제 내용을 어떻게 부여할 것인가?

우선 강제 사용의 금지가 그 핵심 요소다. 그러나 이것이 정확히 무엇을 뜻하는지 이해하는 것이 중요하다. 사회계약은 특별한 능력이나 힘을 가진 사람들의 자연적 이점을 모두 제거하는 체계일 필요가 없다. 그런 식의 외형적 평등은 사람들을 평등한 승산 아래 목숨을 건 투쟁으로 몰아넣음으로써 달성할 수 있을지 모르지만, 그것으로 평화가 성립되지는 않는다. 오히려 평화가 확보된 뒤에는, 기질·재능·취향·체력의 자연적 차이들이 그대로 보존되어야 한다. 그래야 투자, 노동, 거래에서 발생하는 이익이 극대화될 수 있기 때문이다. 실제로 고전적 공리주의와 사회계약론이 서로 가까운 이유는 둘 다 동일한 목표를 추구하기 때문이다. 사회계약론자는 상호 교환의 논리로 참여자들의 효용을 극대화하는 제도를 설계하고, 공리주의자는 강제를 통제하는 일반규칙이 모든 사회질서의 가장 시급한 과제임을 이해하면서 동시에 거래이익을 촉진하는 규칙의 중요성도 이해한다. 어느 쪽이든, 강제의 상호 포기는 그 자체로 포괄적 평화조약이지, 자연적 차이를 모두 도덕적으로 무의미하다고 보는 롤스적 세계로 넘어가기 위한 첫 단계가 아니다.

II. 심리적 해악

*Forbidden Grounds*를 향해 자주 던져진 또 하나의 비판은, 이 책이 경쟁의 경제논리를 지나치게 강조한 나머지 인종이나 성별을 이유로 거절당할 때 발생하는 심리적·상징적 효과를, 특히 여성과 소수자에게 미치는 그 효과를 개탄스럽게도 이해하지 못하고 있다는 것이었다. 그러나 나는 경제적 문제를 강조한 것이야말로 1964년 민권법의 원래 충동과 잘 들어맞는다고 본다. 그 법의 지지자들은 흑인들이 일반 노동시장에서 비합리적으로 배제됨으로써 사회적 생산성이 손상된다고 생각했다. 클라크 상원의원은 "경제야말로 인종 문제의 핵심이다"라고 말했다. 나는 그 말을 그대로 받아들일 충분한 이유가 있었다.

오늘날 심리적 해악이 새롭게 강조되는 것은 강점의 표시가 아니라, 오히려 민권법이 입법 당시 약속했던 경제적 이익을 실제로는 제공하지 못했다는 실패의 산물로 보아야 한다. 특히 청년층에서 두드러지는 높은 흑인 실업률, 전반적 교육수준의 저하, 무기력감의 확산, 범죄 증가 등은 지난 30년의 특징이었고, 그것을 반차별법에 조용히 반대하던 소수 반대자들의 탓으로 돌릴 수는 없다. 오히려 나는 지난 30년간의 많은 개혁이 반차별법과 똑같은 방식으로 역효과를 냈다고 본다. 더 높은 사회보장세와 고용세, 최저임금 인상은 그 분명한 사례다. 물론 오늘날의 사회문제가 어디서 비롯되었든, 그러한 대규모 실패는 반차별법의 고전적 정당화를 예전만큼 설득력 있게 보이지 않게 만들었다. 그래서 그 빈틈을 메우기 위한 대안적 정당화가 모색되었고, 심리적 해악에 대한 호소는 거래거절이나 차별을 외적 해악의 범주 안으로 끌어들여, 전통적으로 불법행위법상 책임이 인정되던 영역에 넣으려는 시도라고 볼 수 있다. 이는 동시에 많은 사람들이 어떤 차별적 관행을, 그것이 노골적이든 은밀하든, 얼마나 모욕적으로 느끼는지를 다시 보여준다.

이런 해악의 수준을 보여주기 위해, 라니 기니어 교수는 한 흑인 중상류층 전문직 여성의 최근 경험담을 소개했다. 매우 훌륭한 자격을 갖춘 그 여성은 한 백인 보안요원에게 절도 혐의로 잘못 체포되었고, 수갑이 채워진 채 사람들의 조롱 속에서 가게 밖으로 끌려나갔다. 이 사건 묘사는 분명 개탄스럽다. 그러나 이것이 고용에서의 차별 문제와 무슨 관련이 있는가? 우선 중요한 점은, 내가 옹호하는 법질서 아래서도 이런 사건은 구제 없이 방치되지 않는다는 것이다. 허위체포, 불법감금, 극단적이고 충격적인 행위에 의한 고의적 정신적 고통 유발은 모두 원고와 피고의 인종과 무관하게 적절히 인정되는 보통법상 불법행위다.

법적 구제가 가능한가가 문제라면, 우리는 이미 확립된 법규범을 참조하면 된다. 어떤 면에서 이 사건은 '극단적이고 충격적인 행위'라는 불법행위의 요건에는 다소 못 미쳐 보인다. 피고 측 종업원이 실제로 범죄가 저질러졌다고 선의로 믿었고, 현장을 본 고객들이 실수를 알려주자 곧바로 석방에 동의했기 때문이다. 허위감금이나 명예훼손 소송도 선의와 상당한 이유에 기초한 특권 때문에 복잡해질 수 있다. 하지만 그 여성에게 일어난 불행이 아무리 크다 하더라도, 그것은 생명·신체·신체기능의 상실과는 거리가 멀다. 허위 구금은 기껏해야 불법행위법의 경계선에 걸쳐 있는 사례이지, 그 핵심에 놓인 사례는 아니다. 공동체적 삶에서 서로 다른 기질이 충돌하며 생기는 수많은 마찰과 짜증으로부터는, "정신적 피부를 좀 더 두껍게 만드는 것"이 법보다 나은 보호일 수 있다.

이에 대한 즉각적 반론은, 이런 분석이 사건 당사자들의 인종·성별·계급을 고려하지 않기 때문에 둔감하다는 것이다. 다시 말해 내가 또 한 번 "핵심을 이해하지 못하고 있다"고 말할 수도 있을 것이다. 하지만 나처럼 느린 사람에게는 그 추가적 차원이 도대체 무엇인지 그렇게 자명하지 않다. 체포와 공개적 수모를 평온하게 받아들이는 사람은 없기 때문이다. 실제로 내가 기니어의 사례를 한 백인 남성 법학교수에게 이야기했더니, 그는 자신도 최근 약국을 나가다가 도난경보를 울려 보안요원에게 끌려간 적이 있다고 말했다. 아스피린 병 하나가 다운재킷 후드 속에 떨어져 들어가 경보를 울렸다는 것이었다. 그는 그 경험을 깊은 수치심과 진짜 공포로 기억했고, 헌법이나 계약법에 대한 그의 이해는 그 순간의 개인적 위험 앞에서 아무 도움이 되지 않았다고 했다. 그는 자신이 백인이고 보안요원이 흑인이며 가게 주인이 히스패닉이라는 점이 그렇게 중요하지 않았다고 느꼈다. 공포의 핵심은 자신이 하지도 않은 범죄로 체포 직전까지 갔다는 사실 그 자체였다. 나 역시 그 처지를 충분히 공감할 수 있다. 그 상황에서는 나도 무력감을 느낄 것이기 때문이다. 법학 학위나 학술 업적은 아무 소용이 없다. 그 친구의 두려움이 똑같이 잘못 체포된 흑인 여성보다 더 컸는지 아닌지는 모르지만, 적어도 여기서는 그 차이가 별로 중요하지 않다. 이런 비교는 원래 어렵다. 다만 분명히 잘못된 관점은, 백인 남성은 허위체포로 인한 심리적 해악에 거의 영향을 받지 않는다는 식의 기준점이다.

이렇게 보면 인종·계급·성별이라는 끓어오르는 문제를 법적 분석에서 일단 배제하는 것은

약점이 아니라 숨은 강점이다. 예컨대 허위체포 법리를 인종·성별·계급의 모든 조합에 따라 촘촘한 행렬표처럼 달리 적용하는 것은 법체계에 매우 서툴고 해로운 일이 될 것이다. 행위 중심으로 법규칙을 만들고 지위 중심으로 만들지 않는 능력은, 아리스토텔레스가 보기에 발달된 교정적 정의 체계의 특징이었다. 특정 사회적 범주가 법적 분석에 중요하지 않다는 그의 기본 논지는 옳다. 물론 누군가는 이 사건을 오늘날 미국 인종관계의 타락을 보여주는 사례로 길게 말하고 싶을 수 있고, 어떤 맥락에서는 특별한 고통을 인정해야 한다고 주장할 수도 있다. 그렇다면 오히려 더욱 엄밀해야 한다. 기니어가 소개한 사례에서는 다른 현장 목격자들이 모두 체포된 여성을 도와주었고, 동료 직원을 감싸며 은폐하려 하지 않았다는 점도 주목할 만하다. 경찰과 치안판사가 그녀를 어떻게 대했는지, 이런 사건이 얼마나 자주 왜 발생하는지까지 알아야 비로소 사회적 태도를 제대로 이해할 수 있다.

그렇다 해도 이 사례가 고용상 반차별법에 대해 말해주는 것은 무엇인가? 정확히 말하면 아무것도 없다. 인종·성별·계급은 이야기의 서사적 힘을 더할 수 있지만, 이 사건이 강한 이유는 그 여성에게 실제로 강제력과 공개적 수모가 가해졌기 때문이다. 아무리 뛰어난 작가라도, 인종을 이유로 한 단순한 채용 거절만으로는 같은 힘을 지닌 이야기를 만들어내기 어렵다. 기니어가 했던 것처럼 공격, 구금, 공개적 망신, 명예훼손, 기만의 요소를 생생하게 덧붙이지 않는 한 말이다. 반차별법 위반은 얼마든지 공손한 어조로도 가능하다. "불편을 겪으셨다면 죄송합니다만, 우리 기준을 충족하는 사람만 채용할 수 있으며 다른 곳에서 자리를 얻으시길 바랍니다." 심리적 해악은 바로 이런 장면을 기준으로 평가해야 한다. 자유지상주의 전통이 힘을 실어주는 더 극적인 사례를 끌어와서는 안 된다. 반차별법은 바로 그 전통을 거부하는 법이기 때문이다.

또한 채용 거절로 인한 환원 불가능한 심리적 해악을 정부개입의 근거로 삼으면 새로운 어려움이 생긴다. 차별법의 범위를 둘러싼 오래된 질문이 모두 되살아난다. 이런 해악으로부터 보호받아야 하는 것은 특정 계층의 사람들뿐인가? 거절에서 오는 심리적 상처는 인종과 성별을 막론하고 누구나 경험한다. 집단 간 평균 차이가 존재한다 하더라도, 집단 내부 편차 역시 크기 때문에 예민한 백인 남성이 강인한 흑인 여성보다 더 쉽게 상처받을 수도 있다. 이렇게 연속적이고 정도의 차이가 큰 현상을 두고, 누구의 해악에는 법이 반응하고 누구의 해악에는 사회가 무관심해도 되는지 경계선을 긋기란 어렵다. 게다가 이런 심리적 해악이 법적 구제 없이 늘 방치되는 다른 해악보다 더 심각하다고도 단정할 수 없다. 정치적 견해 때문에 교수직을 얻지 못했다는 말을 들으면, 인종이나 성별 때문에 거절당했다는 말을 들었을 때만큼이나 분노할 것이다. 학문적 논쟁 도중 개인적 모욕을 퍼부으면, "백인 남자의 말은 들을 가치가 없다" 같은 진부한 말보다 오히려 더 화가 날 수도 있다. 또 흑인 사회에 에이즈를 퍼뜨린 책임이 유대인 의사들에게 있다고 공개적으로 비난하는 연설을 들으면 훨씬 더 큰 충격을 받을 것이다. 하지만 이 어느 경우에도 고용 반차별법은 나에게 법적 구제를 제공하지 못한다.

일반적으로 말해, 법의 올바른 대응은 사람들이 모욕적이고 무례한 말에 대해 곧바로 법에 호소하지 않는 법을 배우는 데 있다. 어떤 경우에는 무시하는 것이 적절하고, 어떤 경우에는 맞받아치는 것이, 또 어떤 경우에는 차분하고 냉정하게 대응하는 것이 적절하다. 반면 자유지상주의자들이 채용 거절로 인한 심리적 해악에 법적 구제를 제공하려 한다는 말은 반복되어 왔지만, 내가 아는 어떤 자유지상주의자도 그런 입장을 취한 적이 없다. 만약 누군가 정말 그렇게 주장했다면 그는 소송이 아니라 비판을 받아야 한다. 물론 심리적 해악이 진짜 불법행위, 예컨대 허위체포 같은 행위의 결과로 발생했다면, 그것은 보통의 불법행위 원칙에 따라 전면적으로 배상되어야 한다. 일단 피고가 타인의 경계를 침범했다면, 건전한 법이론은 인종과 무관하게, 그리고 법체계가 감당 가능한 한도까지, 모든 형태의 해악을 완전하게 보호할 것을 요구한다.

IV. 상징적 해악과 사회적 의미

차별이 초래하는 해악에 대한 지속적인 우려는 피해자가 겪는 심리적 해악에서 멈추지 않는다. 그것은 차별적 행위가 수행될 때 생겨나는 더 확산적이고 사회적이며 상징적인 해악으로까지 확장된다. 그러나 여기서도 마찬가지로, 어떤 사람의 행동이 특정 상징을 거슬렀다는 이유만으로 그에게 공적 강제를 행사할 수 있게 해주는 일관된 이론은 없다.

상징적 문제로 논점이 이동하면 또 다른 어려움이 생긴다. 민권법의 원래 초점은 일자리 창출, 노동조건 개선, 직장에서의 개인적 존엄 인정에 있었다. 그런데 상징 문제는 이런 관심을 뒤로 밀어내고, 민권법에 대한 사고를 사적 고용결정이 더 큰 사회적 무대에 미치는 비물질적 파급효과 쪽으로 옮긴다. 마치 당사자들 사이에서는 합법적인 사적 차별 행위가 사회 전체에 부정적 외부효과를 만들어내므로, 그 자체로 정부의 금지를 정당화한다는 식이다. 그러나 이렇게 말하는 순간 전혀 새로운 장애물이 등장한다. 매우 단순하게도, 이런 수정된 이론은 표현의 자유와 관련해 गंभीर한 헌법 문제를 일으킨다. 누군가 색맹적 법질서 속에서도 적극적 우대조치에 따른 채용이 중요하다고 공개적으로 주장한다고 해서, 그 발언이 우리 국가 정체성을 구성하는 지배적 합의를 약화시킨다는 이유만으로 보호를 잃는다고는 아무도 말하지 않을 것이다. 그렇다면 다른 모든 정당화가 실패했을 때, 왜 상징적 손실이 차별적 채용 금지를 유지하는 근거가 되어야 하는가? 지금도 누군가 Title VII의 상징적 해악이 상징적 이익보다 더 크다고 주장하는 것은 위법이 아니다. 지금도 고용주가 법에는 따르면서도 그 법의 강제를 못마땅해한다고 말하는 것은 위법이 아니다. 만약 Title VII가 당대 핵심 논쟁의 방향을 공적으로 통제하기 위한 수단으로 정당화된다면, 그 법은 헌법적 덤불숲에서 벗어날 수 없다. 심지어 Title VII를 지지하는 사람들, 예컨대 미국시민자유연맹조차도, 일부 시민의 깊고 진지한 모욕감만으로는 타인이 자기 소유 재산 위에서 자기 국기를 태우는 것을 막을 수 없다는 현재의 헌법적 이해를 강하게 지켜왔다. 그렇다면 공적 강제로 공적 논쟁의 방향을 통제하려는 것이 Title VII의 핵심 정당화 중 하나라는 주장은 그 법을 매우 곤란하게 만든다.

물론 그렇다고 해서 사회적 관행이 초래하는 깊은 상처와 해악에 모두 귀를 막아야 한다는 뜻은 아니다. 여기서 중요한 것은 법이론의 쓰임뿐 아니라 한계를 인식하는 일이다. 법체계가 묻는 핵심 질문은 "이 행위가 바람직한가, 칭찬할 만한가, 자비로운가, 현명한가"가 아니다. 훨씬 더 좁고 집중된 질문, 즉 "이 행위에 대응해 공적 강제를 사용하는 것이 정당한 사회적 반응인가"를 묻는 것이다. 우리 대부분, 어쩌면 모두가 최소한의 사회적 기준에도 못 미친다고 생각하는 행동은 얼마든지 있다. 무례함, 거침, 둔감함, 조급함, 상스러움, 불관용을 다루지 않는 사회행동 이론은 빈약하고 부적절하다. 그러나 이런 사회적 이해의 위반에 대해서는 공적 강제가 뒷받침하지 않는 사회적 제재 체계가 발전하는 것이 적절하고, 어쩌면 필수적이다. 반대로 정중함, 세련됨, 공감, 인내, 존중, 개방성의 가치를 인정하지 않는 사회행동 이론 역시 마찬가지로 빈약하다.

그렇다고 공적 강제가 악을 처벌하고 덕을 촉진하는 데 사용되어야 하는 것은 아니다. 그 중간지대는 다른 사회적 통제수단이 맡아야 한다. 자선을 생각해보면, 우리는 법규범 준수와 완전한 취향의 주관성 사이에 광대한 미표시 영역이 존재한다는 사실을 잘 알고 있다. 이른바 불완전 의무, 즉 양심에는 구속력을 가지지만 법적으로 강제되지는 않는 의무의 오랜 전통은 단순한 말장난이 아니다. 그것은 인색하고 이기적인 사람들이 타인이 고통받는데도 자기 것을 꼭 움켜쥐도록 허용하기 위한 핑계도 아니다. 법적으로 강제할 수 없더라도 그 의무는 여전히 의무로서 중요하다. 법체계가 선호를 그 가치에 따라 정교하게 등급화하지 못한다고 해서, 우리가 다른 사람의 삶의 방식이나 우리 자신의 삶의 방식을 도덕적으로 무관심하게 보아야 하는 것은 아니다. 바닐라와 딸기 아이스크림 사이 선택처럼 순전히 사적인 문제도 있지만, 분명 사회적 제재를 낳아야 하고 또 낳는 선택도 있다.

이 점은 차별 문제에도 그대로 적용된다. 차별은 사회 전체가 깊이 우려하는 주제이지만, 그렇다고 해서 모든 사적 당사자가 자기 거래상대를 선택할 절대적 권리를 가진 이상, 그들이 차별하거나 배제할 권리를 자랑스럽게 휘둘러야 한다는 뜻은 아니다. 어떤 상호작용에서 배제당한 사람은 다음 번에는 권력과 영향력을 가진 위치에 설 수 있다. 법이 차별을 허용한다고 해서 그 역시 차별해야 하는 것은 아니다. 그는 자신이 속한 사적 제도를 변화시켜 자신이 인식한 해악에 대응하도록 만들 수 있다. 자신이 속한 조직 내부에서는 특정한 행태를 핵심적 잘못으로 규정할 수 있다. 굳이 국가가 똑같은 의무를 다른 이들 목구멍에 밀어 넣을 필요는 없다.

이런 사회적 합의를 법이 어느 정도 반영할 수도 있다. 다만 Title VII처럼 경직된 명령이어서는 안 된다고 이언 에어스 교수는 흥미로운 제안을 한다. 반차별 규범을 강행규정이 아니라 기본규정, 즉 "별도의 명시가 없는 한" 기업은 인종·성별·연령·장애 등을 이유로 차별하지 않기로 합의한 것으로 본다는 방식이다. 그러나 이 규정이 기본규정이므로 기업은 "우리는 고용계약을 자유해고 원칙에 따라 운용할 권리를 보유한다"는 식으로 계약

을 통해 그 규정에서 벗어날 수 있다. 에어스의 생각으로는, 노골적으로 "우리는 차별할 의사가 있다"고 선언하려는 기업은 거의 없을 것이다.

그의 말처럼 초기 규정의 설정이 자유계약 세계에서도 최종 결과에 상당한 영향을 미칠 수는 있다. 하지만 나는 자발적 계약 세계에서 현재의 방대한 민권법 체계가 지금과 비슷한 최종 상태로 유지되리라고는 거의 믿지 않는다. 예컨대 연령 문제만 보더라도, 기업들은 과거 거의 모든 고용계약에 명시적으로 포함되어 있던 정년조항을 곧바로 다시 계약에 넣을 것이다. 그리고 ADA 준수비용이 워낙 크기 때문에, 많은 기업은 비판을 감수하고서라도 그 부담을 피하려 들 것이다. 이른바 핵심 사안인 인종과 성별 문제에서도, 예리한 계산은 Title VII가 현재 요구하는 많은 내용을 빠르게 허물어뜨릴 것이다. 불균형 효과 이론은 사라질 것이고 표준화 시험은 광범위하게 도입될 것이다. 집단소송도 과거의 일이 될 것이다. 고의적 차별의 경우에도 어떤 기업은 이를 분명히 요구할 수 있다. 이를테면 "모든 노동자는 아침 기도모임에 참여해야 한다" 같은 식이다. 게다가 에어스의 기본규정이 적극적 우대조치에 대해 찬성으로 설정되어야 하는지, 그렇다면 그 범위는 어디까지 허용되어야 하는지도 간단하지 않다.

설령 현재 법률 문언을 그대로 기본규정으로 옮겨 놓는다고 하더라도, 많은 기업은 특정 경우 특정 선을 따라 차별 의사가 없음을 매우 빠른 속도로 선언할 것이다. 시장압력이 너무 크기 때문이다. 그러나 그 경우에도 기본규정은 상당히 수정될 것이다. 분쟁은 사내 조정이나 중재로 처리될 것이고, 손해배상액은 크게 제한되며, 입증은 명백하고 설득력 있는 증거를 요구하게 될 것이다. 실제로는 법의 기본규정이 전통적인 자유해고 원칙으로 남아 있어도 이런 변화 상당수는 자연히 생길 것이라고 나는 본다. 노동시장의 넓은 범위에서 지속적으로 인력을 공급받아야 하는 기업들은, 거대한 인력시장의 일부를 잃지 않기 위해 자발적으로 강한 비차별 조치를 취할 가능성이 높기 때문이다. 그렇기 때문에 민권법을 뒤집을 수 있는 기본규정 세트로 바꾸자는 제안은 나로서는 환영할 만하다. 그것은 계약 메커니즘 전체를 문제 해결에 동원하기 때문이다. 이 제안에 격렬하게 반응할 사람들은 나보다 오히려 에어스의 동료들일 것이다.

V. 반차별원칙의 다른 시장으로의 확장

A. 공공편의시설

심포지엄에서는 *Forbidden Grounds*가 다른 시장에서의 차별 문제를 충분히 다루지 않았다는 비판도 제기되었다. 특히 에어스 교수는 공공편의시설, 주택, 자동차 소매시장이라는 세 영역에서 반차별법이 어떤 역할을 해야 하는지를 묻는다. 따라서 내가 *Forbidden Grounds*에서 제시한 입장에 비추어 이 영역들에 어떻게 접근할지 밝히는 것이 유익하다.

1964년 민권법 논쟁 당시 공공편의시설 규정은 논쟁의 중심에 있었다. 호텔이나 운송업

의 많은 업체가 흑인을 거부하거나 백인과 동등한 조건으로 대우하지 않는 현실은 국가적 수치로 여겨졌고, 이 영역에 민권법을 확장하는 데 원칙적 반대는 거의 없었다. 실제로 그 법은 이러한 관행의 지배를 거의 만장일치에 가까운 수용 속에서 깨뜨렸다. 정치적 신중함의 차원에서는 "고장 나지 않았다면 굳이 고치지 말라"는 격언을 따르는 것이 현명할 때가 많고, 그런 이유만으로도 공공편의시설에서의 반차별원칙은 비판을 초월한 것처럼 보인다.

그러나 언제나 그렇듯 이 입장에도 숨은 위험이 있다. 공공편의시설에서 차별을 원칙적으로 용인할 수 없다고 하는 순간, ADA가 만들어내는 막대한 혼란에 대해 원칙적으로 저항할 단단한 선도 사라진다. 차별은 원칙상 금지되고, 다만 비용과 합리적 편의라는 흐릿한 기준에 따라 어떤 차별이 어느 정도까지 허용될지만 남는다. 보기에는 선해 보이는 원칙 진술이 실제로는 적용과 영향 면에서 훨씬 더 논쟁적인 확장을 불러들이는 셈이다.

물론 원칙적으로는 공공편의시설법이 *Forbidden Grounds*의 기준을 충족하는지 제대로 질문할 수 있다. 여기서는 시설을 분리하거나 통합 상태로 유지하기 위해 사적 폭력이 사용될 경우, 국가가 공적 강제로 대응해야 한다는 점이 먼저 도출된다. 따라서 반차별법이 사적 폭력에 맞서는 값싸고 효과적인 대응수단으로 기능한다는 점을 보여줄 수 있다면, 이론상 정당화될 수도 있다. 적대적 분위기 속에서 차별 없는 서비스를 제공하려는 기업은 인종적 정책을 강요하려는 이들로부터 공격과 협박을 받을 수 있다. 강한 반차별법은 그런 기업에게 어차피 하고자 했던 일을 하라고 명령하는 동시에, 그렇지 않으면 방어하기 어려웠을 사적 위협으로부터 보호막도 제공할 수 있다. "법적 제재를 피하려면 어쩔 수 없었다"는 말은, 옳은 일을 하면서도 그 선택을 직접 떠안지 않는 방식이 될 수 있다. 만약 소수의 업체만이 정말로 분리정책을 원했다면, 이런 논리는 폭력 범위를 줄이기 위한 다소 과잉적인 수단으로 어느 정도 설득력을 가질 수 있다. 하지만 오늘날에는, 설령 과거에 이런 정당화가 어느 정도 가능했다 하더라도, 지금은 거의 설득력이 없다고 나는 본다. *Plessy v. Ferguson* 사건을 떠올려보라. 거기서 분리는 국가 규제로 강제되었고, 오히려 규제받던 기업들이 그것에 반대했다.

공공편의시설에 비차별원칙을 부과하는 두 번째 가능한 정당화는 독점력의 억제다. 역사적으로 이 설명은 전통적 서사와 잘 들어맞는다. 과거에는 길 위의 여행자가 선택할 수 있는 여관 하나, 운송수단 하나뿐인 경우가 적지 않았고, 그들의 독점적 지위는 인종이나 성별과 무관하게 비차별의무로 적절히 통제되었다. 물론 그 비차별의무도 비용에 기초한 차별은 허용할 정도의 유연성을 가져야 했다. 철도 승객과 여관 손님이 모두 동일한 요금을 내야 하는 것은 아니었고, 더 좋은 편의시설에는 더 높은 가격을 받을 수 있었다. 특정 노선의 비용이 더 크면 운임도 달라질 수 있었다. 다만 핵심은, 공통운송업자와 여관은 비차별의무의 대가로 초기 투자에 대한 정당한 수익을 보장받았다는 점이다. 이런 법규칙의 목적은 자유로운 진입이 불가능한 체제의 불편을 상쇄하는 데 있었다.

하지만 오늘날 대부분의 경우 상황은 매우 다르다. 사실상 독점력을 가진 여관은 거의 없고, 운송업체 역시 많지 않다. 그렇다면 *Forbidden Grounds*의 이론에 따르면, 과거의 비차별 제한은 해제되어야 한다. 그리고 무슨 해가 생기겠는가? 오늘날 어느 대기업이 인종이나 성별을 이유로 배제정책을 채택할 것이라고 생각하는 사람이 있는가? 설령 채택한다 한들, 시장에서 그 전략으로 이익을 얻을 수 있다고 믿는 사람이 있는가? 이 관행이 비합리적이라는 직관은 바로 그렇기 때문에 옳다. 이런 환경에서의 차별은 관련된 모두에게 손해가 되는 전략이기 때문이다. 오히려 공공편의시설을 규율하는 Title II를 폐지한다면, 수많은 전국적 기업이 자발적으로 강력한 비차별원칙을 채택함으로써 상징적 이익이 생길 수도 있다. 기업들이 법 때문에가 아니라 자기 의지로 그렇게 한다는 것이 분명해지면, "어차피 법이 시켜서 하는 일"이라는 냉소적 시선을 조금은 약화시킬 수 있기 때문이다.

더 나아가 경쟁적 상황에 있는 사적 시설에도 비차별원칙을 계속 강요하는 것은 गंभीरहा 부정적 파급효과를 낳는다. ADA의 과도한 의무가 하나의 예다. 또 각종 사적 클럽과 결사가 공공편의시설로 분류되어 반차별법의 제한을 받을 위험도 있다. 그런데 모두가 똑같은 최소 입회 기준을 강제로 따르게 되는 사회가 정말 더 나은 사회인가? 여성 전용 단체, 흑인 혹은 히스패닉 단체가 설 자리는 전혀 없어야 하는가? 법학전문대학원에서 흑인 법학생회, 히스패닉 법학생회, 아시아계 법학생회, 기독교 법학생회, 유대인 법학생회를 모두 폐쇄하고, 다른 어떤 유사 단체도 만들지 못하게 해야 하는가? 또 그런 단체에 가입한 사람들이 다른 개방적 단체에는 전혀 가입하지 않는다고 가정해야 하는가? 집단 간 협력은 전혀 없다고 보아야 하는가?